

1500031-81.2021.8.26.0592
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Paolo Pellegrini Junior
Comarca: Bastos
Foro: Foro de Bastos
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... inexistente.

Nesse sentido: "Entorpecente - Tráfico - Desclassificação para uso indevido
Inadmissibilidade se ausente a prova da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325).
No mesmo sentido: "Entorpecentes - Tráfico - Configuração - Autoria e materialidade
demonstrada - Prova - Depoimento de policiais - Validade - Desclassificação para a
figura do artigo 16 da Lei de Tóxico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bastos
Foro de Bastos
Vara Única
Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500031-81.2021.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500031-81.2021.8.26.0592
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027192/2021 - DEL.POL.BASTOS,
15953047 - DEL.POL.BASTOS, 54/21/401 - DEL.POL.BASTOS, 2027192 - DEL.POL.BASTOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE DARLEY BATISTA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO PELLEGRINI JUNIOR

Vistos.

JOSÉ DARLEY BATISTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo
processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo
narra a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 14h29, na Rua Bahia,
próximo ao nº 332, Vila Guarujá, nesta cidade e comarca de Bastos, JOSÉ DARLEY
BATISTA DOS SANTOS, qualificado a fls. 07, trazia consigo, para fins de tráfico, 02

pedaços de tabletes de maconha, com peso líquido de 44,28 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor VW/Gol CLI, placas BPP-6493, de Bastos-SP, quando foi abordado pela viatura policial. Nesse instante, José Darley indicou que transportava drogas na lateral do banco do motorista. Realizada busca no automóvel, os policiais encontraram no local indicado pelo denunciado um pedaço de tablete de maconha, embalado em plástico amarelo e mais um tablete de maconha, embalado da mesma forma, que estava oculto sob o banco traseiro do veículo.

Ainda na ocasião, em procedimento de revista, foi localizada uma porção de maconha que estava em poder do passageiro, seu irmão, o qual foi liberado pela autoridade Policial.

Por fim, José Darley indicou que havia uma balança de precisão na sua residência, localizada no Chácara Primavera, seção Glória I, apreendida pelos policiais militares. A quantidade, a natureza, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão da balança de precisão e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o denunciado praticava o comércio ilícito de drogas.

Auto de exibição e apreensão a fls. 14/15.

Laudos de constatação a fls. 19/21.

Em decorrência o acusado foi autuado em flagrante delito (fls. 01/02).

Por ocasião da realização de audiência de custódia foi concedida liberdade provisória (fls. 71/72).

O acusado foi citado pessoalmente para apresentar defesa preliminar (fls.122).

Pelo Patrono do réu foi ofertada resposta escrita à acusação (fls.123/129).

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 137/138).

No decorrer da instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 155).

Ao final o réu foi interrogado sobre os termos da denúncia.

Em debates orais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos moldes da inicial acusatória, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.34/063 na maior diminuição e que a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por duas restritivas de direitos e fixado regime aberto (fls. mídia).

A Defesa postulou pela improcedência da ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, requereu aplicação do artigo 28 da lei de drogas ou o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Drogas; a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda; a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (mídia).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente destaco que a denúncia é peça hígida, que atende a todos os requisitos legais. Houve precisa e detalhada descrição dos fatos, a permitir o exercício da ampla defesa e contraditório.

Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, operou-se o recebimento da mesma, entendimento que encontra amparo na jurisprudência pátria:

"Preliminar de Inépcia da Denúncia - 1. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. 2. No presente caso, verifica-se que a denúncia foi oferecida com base nos elementos existentes no inquérito policial, especificando as condutas dos agentes envolvidos no crime, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de forma a preencher os requisitos previstos no artigo 41 do Código Processo Penal, não havendo qualquer prejuízo para que o apelante exercitasse a ampla defesa e o contraditório. 3. Preliminar rejeitada" (TJ/ES - APELAÇÃO Nº 0000879-38.2011.8.08.0029 - REL. JOSÉ LUIZ BARRETO

VIVAS - 2ª CÂMARA CRIMINAL - J. 17/04/2013 - G.N).

No mérito, a ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A materialidade encontra-se positivada por toda a prova oral colhida no decorrer da instrução processual, bem como pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência alusivo aos fatos, auto de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação provisória, exames químico toxicológicos, que constatarem a natureza dos entorpecentes apreendidos, a denotar nocividade à saúde pública. Ademais, neste tópico não há divergência entre as partes.

A autoria e propósito de traficância são incontestes.

Inquirido na fase policial, por ocasião do flagrante, o acusado disse que dispensa a assistência de advogado. Seu pai se encontra nesta Delegacia de Polícia. É solteiro e não tem filhos. Trabalha na roça e ganha seiscentos Reais por semana. Nesta tarde veio com seu irmão para a cidade em seu veículo quando acabaram sendo abordados pelos Policiais Militares. Eles apreenderam duas porções de maconha que estavam no interior do carro. A droga se destinava a seu próprio consumo. É usuário de maconha há vários anos. Seu irmão também é. Ambos não tem nenhum envolvimento no tráfico de drogas. Seu irmão não sabia que tinha drogas no carro. Essa maconha foi adquirida de um desconhecido na praça do Esplanada. Pagou cem Reais pela droga. A balança que estava em sua casa, conforme relatado aos policiais, que foi apreendida, foi comprada para conferir a droga que adquiria e não ser enganado pelos traficantes. Não registra antecedentes criminais (fls. 07).

Em Juízo manteve sua versão dos fatos. Em síntese, disse que é usuário. Que nunca traficou. Que a balança era para pesar os alimentos (mídia)

Todavia, a versão inverossímil apresentada em Juízo pelo acusado não merece guarida.

Mostraram-se seguros e coerentes os relatos dos policiais militares Cláudio Nogueira de Lima e Márcio Padovezi.

O policial Cláudio disse que se encontrava com o Policial Militar PADOVEZZI, quando por volta das 14h29, na alt. do n.º 332 da rua Bahia, nesta cidade, realizaram a abordagem de dois indivíduos que estavam em um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca. Ao serem indagados, o condutor, identificado como sendo JOSÉ DARLEY, disse que tinha uma porção de maconha na lateral do banco que ele ocupava. Sendo verificado que se tratava de um pedaço de tablete de maconha embalado em pedaço de sacola plástica amarela. O acompanhante dele, JOSÉ WANDERSON, que vem a ser seu irmão, nada disse, porém durante revista foi encontrada uma pequena porção de maconha embalada em pedaço plástico branco que estava no bolso da bermuda. Em continuidade a busca encontraram outro pedaço de tablete de maconha também embalado em pedaço de sacola plástica amarela, que estava sob o banco traseiro. Dada voz de prisão em flagrante delito, eles foram apresentados nesta Delegacia de Polícia. Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, JOSÉ DARLEY afirmou que tinha uma balança em sua casa, a qual também foi apreendida.

O policial Márcio disse que estava em serviço com o Policial Militar Nogueira. Por volta das 14h29, na alt. do n.º 332 da rua Bahia, nesta cidade, abordaram dois indivíduos que ocupavam um veículo marca Volkswagen, modelo Gol, cor branca. O condutor do veículo, identificado como sendo JOSÉ DARLEY, disse que tinha uma porção de maconha na lateral do banco do motorista. Foi constatado que se tratava

de um pedaço de tablete de maconha embalado em plástico amarelo. O acompanhante dele, JOSÉ WANDERSON, que irmão dele, não disse nada, todavia durante revista foi encontrada uma pequena porção de maconha embalada em plástico branco que estava no bolso de sua bermuda. Em continuidade à busca encontraram outro pedaço de tablete de maconha, embalado da mesma forma que o primeiro, que estava sob o banco traseiro do veículo. Dada voz de prisão em flagrante delito, eles foram apresentados nesta Delegacia de Polícia.

Tanto na fase policial, como em Juízo, os militares cuidaram de detalhar a abordagem policial e o desenrolar dos fatos, indicando de forma segura o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

O próprio acusado não negou a apreensão do entorpecente e o que se discute nos autos é a finalidade a que serviria a droga e, por toda a prova colhida, forçoso concluir que o réu se dedicava ao comércio ilícito de drogas.

Vejamos.

A prova oral revelou a existência de informações que apontavam a prática do tráfico de drogas pelo acusado. Os militares, diante disso, abordaram o réu, ocasião em que apreenderam em poder do acusado 1,02 e de 44,28 gramas de maconha, conforme laudos n.ºs 31556/2021 e 31561/2021, em lugares diversos do veículo.

A tentativa fantasiosa do acusado de tentar se esquivar da responsabilidade penal alegando que é usuário, não merece credibilidade, além de não ter encontrado qualquer guarida diante do farto conjunto probatório que ampara a acusação. A isso se soma a apreensão da balança de precisão apreendido em sua residência sugestivo de quem realiza a mercancia..

Ademais, difícil acreditar que todas as porções apreendidas em poder do réu eram destinadas a uso próprio, a considerar a sua situação de hipossuficiência financeira.

Aquele que adquire droga para consumo próprio não o faz em grandes quantidades. Pequenas porções, ideais ao deleite do vício, são adquiridas em momentos distintos, secundo as condições financeiras do consumidor. Essa proceder, aliás, não se afigura incomum nem mesmo entre traficantes, sempre com o propósito de ver corar, acaso descobertos, a assertiva de que se destinava ao próprio uso.

Desse modo, as informações que apontavam o envolvimento do acusado com a venda de drogas, os depoimentos dos prestimosos milicianos, a quantidade de entorpecentes apreendidos, a considerar a condição de hipossuficiência financeira do acusado, sugerem a prática do nefasto comércio.

Oportuno consignar, ainda, que os depoimentos dos policiais, prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem o réu de forma gratuita.

Não há nada a colocar sob suspeita a palavra dos militares. É forte a jurisprudência em validar seus testemunhos, como agentes da lei. Nesse sentido: "O depoimento do policial é tão válido como outro qualquer, desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, indeclinável credibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas" (RT 574/401). E mais: "Os policiais não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em cuja fase inquisitorial tenham participado. A eventual inidoneidade tem que ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, pois o simples fato de ser a

testemunha um policial não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento" (RT 594/332). Em idêntico sentido: RTs 394/282, 526/445, 554/420, 558/313, 568/315, 581/311; RJTJ 93/400 e 95/468, dentre tantos.

No mais, a condição de usuário não inibe a traficância.

Para que a conduta seja desclassificada para o delito de porte ilegal de substância entorpecente é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio, o que, no caso, inexistente.

Nesse sentido: "Entorpecente - Tráfico - Desclassificação para uso indevido Inadmissibilidade se ausente a prova da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325). No mesmo sentido: "Entorpecentes - Tráfico - Configuração - Autoria e materialidade demonstrada - Prova - Depoimento de policiais - Validade - Desclassificação para a figura do artigo 16 da Lei de Tóxico - Inadmissibilidade - Pequena quantidade - Irrelevância - Modo de acondicionamento e circunstâncias do flagrante, decorrente de denúncias anônimas, que revelam o fim de comércio - Apelo improvido" (Apelação n.º 269.436-3 - Relator Desembargador Passos de Freitas - j . 01-06-1999). "A pouca quantidade da substância apreendida não afasta a possibilidade de tráfico" (RF 290/335).

Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542). "Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357). "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663) - (TJ/SP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0005372-64.2011.8.26.0156, Rel. Des. Sérgio Coelho, v.u., julgado em 21.02.2013).

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal.

De rigor, portanto, a condenação do réu por infringência ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

O agente é primário, não ostenta Maus Antecedentes (FAC de fls. 30/33 e certidão de distribuição criminal de fls. 158/159), e não há qualquer sinal de que se dedique a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de maneira que faz jus ao reconhecimento da benesse em tela.

No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado balizam o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 -, servirão para a escolha do quantum da redução. Considerando que foi apreendida quantidade não tão portentosa de drogas e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3). Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021); e

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 160,6 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agentes primários que não ostentam Maus Antecedentes, admissível o deferimento da assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos das penas privativas de liberdade que, se o caso, haverão de ser inicialmente cumpridas no regime prisional aberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1508466-06.2020.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a variedade não exorbitantes de drogas não ensejam maior reprovação penal, e não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente. Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; o réu é primário; as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando maior reprimenda.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a penabase no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena em 2/3 (dois terços) na esteira do acima explanado -, e, à míngua de causas de aumento, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, reafirmou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/1990:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

A dizer: a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo compreensão que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, “caput” e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.

3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime aberto para início do resgate da pena corporal, porquanto inferior ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que o réu não é reincidente (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), sendo favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, sempre do Código Penal). Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena

concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ DARLEY BATISTA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Apenado com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime aberto, devidamente substituída por medidas alternativas, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência). O réu permaneceu solto durante o processo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso).

Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, a perda de eventuais valores monetários e objetos apreendidos (balança) em favor do FUNAD. Restou evidente pelo conjunto probatório dos autos a origem espúria dos referidos bens. Oficie-se, pois, informando a decretação do perdimento dos bens referidos. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração caso ainda não tenha sido realizada.

AUTORIZO a liberação do veículo apreendido mediante o pagamento das taxas necessárias, eis que a apreensão foi regular e decorreu da prática de crime, e AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Notifique-se o condenado para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe. Comunique-se à vítima do teor da presente, na forma do art. 201, § 2º, do CPP.

Por fim, condeno o réu ao pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Bastos, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA